

1500023-93.2022.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico: Importar, exportar, remeter, preparar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1500023-93.2022.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500023-93.2022.8.26.0552

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO APARECIDO MACHADO FABIANO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de ADRIANO APARECIDO MACHADO FABIANO, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 e no art. 329, "caput", do Código Penal, em concurso material, afirmando que em 07 de janeiro de 2022, no período da tarde, no cruzamento da rua Vitório Coli com a rua Batista Arnoni, Vila Maria, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, tinha em depósito, 60 porções de "cocaína" com peso líquido de 13,65 gramas, 87 porções de "crack" com peso líquido de 16,26 gramas e 23 porções de "maconha" com peso líquido de 19,52 gramas; bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, opôs-se à execução de sua detenção mediante violência contra os policiais civis Brizano Aparecido da Silva e Luiz Roberto Stringhetta, causando-lhes lesões corporais.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "os policiais civis Carlos, Brizano e Stringhetta se dirigiram para o local dos fatos, notório ponto de

venda de drogas na Vila Maria conhecido como "Biqueira do Bixiga", a fim de verificar a procedência de informação recebida no Setor de Inteligência no sentido de que um indivíduo conhecido como "Paina" ali estaria realizando o tráfico de entorpecentes. Os agentes públicos rumaram para o local em viatura descaracterizada e, após breve campanha, verificaram que o denunciado estava realizando a traficância, eis que visto encostado em um muro servindo algo para outro indivíduo. Ato contínuo, os agentes públicos se aproximaram para abordagem, ocasião em que ADRIANO, ao notá-los, saiu caminhando rapidamente ao passo que o outro indivíduo empreendeu fuga, não sendo identificado. Ao receber a ordem de parada, o denunciado se recusou a cumprir o ato e tentou se evadir, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e algemá-lo, causando com seu ato de resistências lesões corporais nos policiais civis Brizano e Stringhetta, conforme documentos médicos de fls. 34/35 e 36/37. Em busca pessoal, foi encontrada no bolso de sua bermuda a quantia de R\$ 30,00 em moeda corrente fracionada. Na sequência, o policial civil Brizano foi até o local onde o denunciado estava e encontrou sobre o muro uma pochete contendo as 87 porções de "crack", 60 porções de "cocaína" e 23 porções de "maconha" acima descritas. Formalmente interrogado em solo policial, ADRIANO confessou a prática delitativa, afirmando que praticava a traficância para sustentar o seu vício em "crack" e que o valor apreendido com ele era produto da venda de entorpecentes (fl. 06). Assim, as circunstâncias apuradas pela polícia civil com a prisão em flagrante de ADRIANO na prática da traficância, o local da prisão, conhecido ponto de venda de drogas, a quantidade de entorpecentes, a forma de disposição fracionada e embalada para a venda, a quantia em dinheiro e a confissão do denunciado demonstram, com segurança, que ele tinha em depósito os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico (finalidade da proteção penal) é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 27/29), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), pelos laudos periciais (fls. 112/114 e 115/117) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

Acerca da resistência, dispõe o Código Penal:

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

A conduta deve, necessariamente, ser praticada com violência ou ameaça (que não precisa ser grave). A simples fuga, ao ser capturado pelos policiais, sem violência, p. ex., é atípica; também é atípica a resistência passiva (sem violência).

A conduta também deve ser anterior ou concomitante ao ato funcional e dirigida contra a pessoa (do funcionário público ou de quem lhe auxilia).

O ato funcional não precisa ser justo, mas precisa ser legal, o que exige que o funcionário público esteja agindo dentro da sua esfera de competência.

A embriaguez não afasta o delito, visto que não há nenhum indicativo no texto legal de elemento subjetivo específico que poderia, eventualmente, ser incompatível com o estado de alteração de ânimo oriundo do uso de drogas.

O crime é formal, pois não se exige que ele consiga impedir a execução do ato. Se conseguir, incide a qualificadora do §1º.

A resistência contra dois funcionários públicos configura crime único.

De acordo com o §2º, se o ato violento (não trata, portanto, da resistência por meio da ameaça) se subsumir a outro tipo penal, haverá concurso de crimes.

Há entendimento jurisprudencial de que nas situações em que o agente xinga e agride o funcionário público, embora os fatos se enquadrem nas figuras do desacato e da resistência, o agente só responderá pelo último, ficando o desacato absorvido.

No caso em análise, há prova da existência e da autoria do delito supracitado.

Comprova-se a existência do crime pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência, que descreve a conduta do acusado de resistência à ordem de prisão perpetrada pelos policiais militares Brizano e Luiz Roberto (fls. 27/29), bem como pelos prontuários médicos dos policiais militares agredidos (fls. 34/35 e 36/37) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria dos crimes também é certa.

A testemunha de acusação, o policial civil Brizano Aparecido da Silva, na fase policial disse que "nesta data, no período da tarde, se deslocou até o bairro Vila Maria, na companhia do Investigador Stingueta e Escrivão Carlos, para averiguação de denúncia de tráfico de drogas; que, segundo a denúncia, a pessoa de Adriano Aparecido Machado Fabiano, vulgo "Paina", estaria promovendo tráfico de drogas no local; que, tão logo se aproximaram do local, avistaram o indiciado, Adriano, encostado em um muro, servindo outro indivíduo, sendo que ao perceber a presença policial deixou o local caminhando rapidamente, enquanto o outro indivíduo se evadiu sem ser identificado; que, ao ser abordado, Adriano resistiu sendo necessário uso de força moderada para contê-lo; que o depoente, durante buscas, acabou por localizar, sobre o muro, onde Adriano estava encostado, uma pochete contendo em seu interior a quantia de 87 pedras de substância semelhante a crack, 60 microtubos de substância semelhante a cocaína e mais 23 porções de substância semelhante a maconha; que, em

busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda de Adriano a quantia de R\$ 30,00, sendo 01 nota de R\$ 10,00 e 01 nota de R\$ 20,00; que Adriano recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado a esta Unidade onde a Autoridade Policial a ratificou; que, nesta Unidade, ciente dos seus direitos constitucionais, Adriano acabou por confessar a autoria delitiva, dizendo que estava vendendo drogas para fins de sustentar seu vício; que, o depoente já conhecia Adriano; que, em vista da resistência à abordagem, restaram lesões leves no depoente no Investigador Stringueta e em Adriano." Em juízo manteve sua versão. Sobre a resistência disse que o acusado se debateu causando arranhões nos agentes policiais. Desculpou-se com os policiais no pronto-socorro. Adriano disse estar vendendo para sustentar seu vício.

A testemunha de acusação, o policial civil Luiz Roberto Stringhetta, na fase policial disse que "nesta data, no período da tarde, se deslocou até o bairro Vila Maria, na companhia do Investigador Brizano e Escrivão Carlos, para averiguação de denúncia de tráfico de drogas; que, segundo a denúncia, a pessoa de Adriano Aparecido Machado Fabiano, vulgo "Paina", estaria promovendo tráfico de drogas no local; que, tão logo se aproximaram do local, avistaram o indiciado, Adriano,

encostado em um muro, servindo outro indivíduo, sendo que ao perceber a presença policial deixou o local caminhando rapidamente, enquanto o outro indivíduo se evadiu sem ser identificado; que, ao ser abordado, Adriano resistiu sendo necessário uso de força moderada para contê-lo; que o Investigador Brizano acabou por localizar, sobre o muro, onde Adriano estava encostado, uma pochete contendo em seu interior a quantia de 87 pedras de substância semelhante a crack, 60 microtubos de substância semelhante a cocaína e mais 23 porções de substância semelhante a maconha; que, em busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda de Adriano a quantia de R\$ 30,00, sendo 01 nota de R\$ 10,00 e 01 nota de R\$ 20,00; que Adriano recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado a esta Unidade onde a Autoridade Policial a ratificou; que, nesta Unidade, ciente dos seus direitos constitucionais, Adriano acabou por confessar a autoria delitiva, dizendo que estava vendendo drogas para fins de sustentar seu vício; que, o depoente também já conhecia Adriano; que, em vista da resistência à abordagem, restaram lesões leves no depoente no Investigador Brizano e em Adriano." Em juízo manteve sua versão. Disse que Adriano exigiu que usassem um pouco de força para contê-lo. Ele disse que não queria os agredir que só reagiu porque estava sob efeito de drogas. Adriano não quis se deixar algemar, causou escândalo na rua. Depois de algemado se acalmou.

ADRIANO APARECIDO MACHADO FABIANO, em declarações perante a autoridade policial, disse que "nesta data, estava promovendo a venda de drogas no Bairro Vila Maria quando foi abordado por policiais civis; que a droga apreendida era a droga que estava sendo vendida; que o interrogando afirma que somente estava vendendo droga, uma vez que é usuário de crack e precisava sustentar seu vício; que sobre o valor apreendido em seu poder, afirma que era proveniente de algumas vendas; que realmente desobedeceu e resistiu a prisão, mas sua intenção não era desrespeitar os policiais e sim pelo fato de estar sob efeito de crack; que esta arrependido do que fez e neste ato solicita um que seja submetido a tratamento de droga." Em juízo se disse culpado das duas acusações. Disse ter fumado uma pedra de crack pouco antes da abordagem policial.

Preliminarmente, aponto que havia justa causa para a diligência policial invasiva, pois, após denúncia anônimas, os policiais civis avistaram a pessoa imputada, em um ponto de tráfico (Rua Batista Arnoni), servindo outra pessoa, o que denota uma causa provável de que estivesse na posse de drogas, situação que é proibida criminalmente.

Neste contexto, é possível afirmar que havia fundada suspeita de que a pessoa imputada estivesse na posse de objetos que constituem corpo de delito de infração penal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Passo ao mérito.

O tráfico ficou incontestado, sendo o réu confesso.

Quanto à resistência o relatado pelos policiais foi tão só a chamada resistência passiva, a qual não enseja a tutela penal.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito

secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.
STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.

(...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, “reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa” (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJE 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. A pessoa imputada possui quatro maus antecedentes (0003183-48.2005.8.26.0472; 0007994-85.2004.8.26.0472; 0008805-69.2009.8.26.0472; 0005836-86.2006.8.26.0472). Como cada um deles é suficiente para majorar a pena em um sexto do intervalo, fixo a pena-base do tráfico em onze anos e oito meses de reclusão, além de 1166 dias-multa.

Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos (Tema 150 da Repercussão Geral do STF – HC 593.818/SC).

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (0000373-68.2016.8.26.0552). Conforme dispõe o art. 67 do Código Penal, a confissão só tem valor preponderante quando associada à personalidade do réu. No caso, a confissão foi feita sem qualquer demonstração de arrependimento resumindo-se à confirmação do já explicitado no flagrante, de modo que deveria prevalecer a reincidência com um aumento de 1/6 (um sexto). Todavia, tendo em vista a função constitucional dada ao STJ, principalmente na alínea "c" do inciso III do art. 105, e a consolidação do entendimento pela Terceira Seção, a qual reúne todos os ministros das turmas com competência criminal da corte, faço a compensação das circunstâncias e mantenho a pena no patamar indicado.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Sendo o réu reincidente e em razão do montante de pena, o regime é, necessariamente, o fechado. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial fechado. A reincidência também impede a aplicação do redutor, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional. Neste sentido:

A agravante obsta o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, juntamente com a pena corporal, obrigava a fixação do regime inicial fechado e impedia a substituição por restritivas de direitos.

TJSP, Apelação n. 0000411-36.2016.8.26.0599, Rel. Des. Vico Manhães, j. 23.05.2018. Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR ADRIANO APARECIDO MACHADO FABIANO à pena de reclusão, pelo prazo de 11 anos e oito meses, em regime inicial fechado, bem como a 1166 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06; também para ABSOLVER ADRIANO APARECIDO MACHADO FABIANO da acusação de resistência a ele imputada na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Diante da declaração do réu a respeito de sua dependência química, determino que o estabelecimento responsável por sua custódia providencie o tratamento de drogadição após avaliação médica competente.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões (fls. 74/75 e 92/94) de sua prisão cautelar estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do

conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado.

4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas).

5. Ordem denegada.

STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, mormente por conta da elevada sanção e da condição de reincidente específico, qualquer mudança em seu regime prisional.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição ou doação dos seguintes bens: 01 pochete.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 28 de abril de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA